

1503347-76.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... individual. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ADEQUAÇÃO.

Ausente demonstração de dedicação do paciente a atividades criminosas, surge adequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTO TÍTULO CONDENATÓRIO REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A previsão do regime semiaberto para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503347-76.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503347-76.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2277191/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 1488/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2277191 - 02º D.P. SANTOS, 1488/21/010 - 02º D.P. SANTOS, 2277191/2021 - 2º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS MIOTTO

Réu Preso

Vistos.

JEAN CARLOS MIOTTO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal brasileiro porque em 9 de outubro de 2021, por volta das 14h10min, foi preso por suspeita de prática delitiva de roubo impróprio, na Rua Martim Francisco nº 316, Casa nº 05, Encruzilhada, nesta cidade e comarca, tendo subtraído um notebook da vítima e empregado violência física, a fim de evadir-se do local. Em audiência de custódia (pág. 93/94), a prisão foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida a 15 de outubro de 2021 (pág. 122/123). O réu foi citado a pág. 151 e apresentou resposta à acusação, por intermédio de Defensor Público (pág. 154). Não foi decretada a absolvição sumária (pág. 156/157),

sendo então designada de audiência.

No ato, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ainda, realizado o interrogatório do réu (págs. 202/203).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, almejando a fixação da pena acima do mínimo legal, com o reconhecimento da agravante da reincidência, ressaltando que o regime adequado ao caso é o fechado (págs. 208/214).

A Defensoria Pública, por sua vez, sustentou haver insuficiência de provas para acusar o réu e condená-lo à prática de roubo impróprio. Reputando que o acusado negou, expressamente, cometer o delito, a defesa pediu pela absolvição do réu e, subsidiariamente, para o caso de condenação, pela desclassificação da conduta imputada, a fim de que seja configurado o furto simples tentado (pág. 218/225).

É o relatório do essencial.

Passo à fundamentação.

A ação procede em parte.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indiciados por elas e tampouco a responder um a um todos os argumentos." (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

No caso em tela, tem-se a acusação do cometimento do crime de roubo impróprio, consoante a tipificação legal prescrita pelo Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal brasileiro, cujo dispositivo versa:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à possibilidade de resistência:

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

A materialidade do crime está comprovada nestes autos pelo conjunto probatório coligido, especialmente pelos depoimentos apresentados pela vítima e pelas testemunhas, civis e policiais, repetidos quando da audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 202/203).

De maneira similar, a autoria recai sobre o réu.

Analisando as declarações da vítima, por exemplo, atentam-se robustos os indícios da autoria delitiva, sobretudo considerando que, sendo o réu por ela desconhecido, não há de se falar em tentativa de falsa incriminação.

Em sua versão, ela alegou que estava em seu quarto, dormindo, quando um de seus vizinhos, morador ao lado de seu prédio, lhe telefonou para noticiá-lo de que algum desconhecido entrava em sua residência. Neste momento, pulou de sua cama, abrindo a porta do cômodo, quando percebeu que, ao final do corredor, a porta da sala-de-estar se encontrava aberta. Então, de trás de seu quarto, saiu o acusado com o referido notebook em mãos, procurando por uma rota de fuga pela porta da sala. A vítima afirma que obstruiu a passagem e enfrentou o acusado, até que este escapou, porém foi detido na porta do prédio, na presença dos vizinhos, ora testemunhas, e, mais tarde, de dois policiais militares, que prestaram depoimentos similares.

Ao longo das próprias alegações, a vítima reconheceu o acusado, enriquecendo a narrativa dos fatos.

Cabe consignar que em tema de delito patrimonial, a palavra da vítima goza de presunção de idoneidade, sendo preciosa para identificar os autores, posto que referidos crimes são geralmente cometidos na clandestinidade, tendo apenas as partes como envolvidos.

Aliás, no ponto, cumpre destacar que:

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto." (TACRIM; Ap. nº 1.071.263/0 - São Sebastião, 11ª Câmara; rel. Juiz RENATO NALINI; j. 15.9.97; v.u.).

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena,

coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção nos autos."

(JUTACrimSP, 94:341, rel. Juiz CELSO LIMONGI).

Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

Absolvição inadmissível. Confissão parcial. Validade do depoimento dos policiais e reconhecimento efetuado pela vítima. Fuga com os bens subtraídos suficiente para caracterizar a consumação. Violência real que assegurou a subtração do bem.

Impossibilidade do reconhecimento da tentativa. Penas e regime mantidos. Recurso improvido. (TJSP, Apelação 990092205404, 9ª Câmara de Direito Criminal, j.

07/01/2010, reg. 22/01/2010).

PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVAS VÁLIDAS - RECONHECIMENTO. As declarações da vítima são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. ROUBO - CRIME CONSUMADO - RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. Diante da materialidade e autoria delitiva suficientemente provada pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, é cabível o decreto condenatório por roubo consumado. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR CAUSA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO. Não há confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, quando a confissão vem acompanhada de inverídica versão que procura eliminar as causas de aumento da pena, previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal. (TJSP, Apelação 993050247317 - 8945913200000000, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

Apelação - Furto Simples - Artigo 155, 'caput', do Código Penal - Pedido ministerial de condenação - Admissibilidade - Autoria demonstrada - Provas - Depoimento da vítima - Valor probante - Relevância - A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente o furto, cometido na clandestinidade, serve de prova suficiente para o decreto condenatório. Furto consumado em sua inteireza - O crime patrimonial se consuma quando o agente se apodera da "res" com a inversão da posse - Não caracterização da fraude - Qualificadora não utilizada pelo agente para ludibriar a confiança da vítima - Furto simples configurado. Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - Privilégio reconhecido - Pequeno valor atribuído à coisa furtada e acusado que apresentou primariedade, requisitos necessários à concessão do benefício. Regime de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, ^ 2", alínea "c", do Código Penal. Recurso ministerial provido. (TJSP, Apelação 990092229176, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - Nossa jurisprudência é de entendimento que: cometido o crime de roubo a coberto de qualquer testemunha, ganha especial relevância a palavra da vítima, sendo suficiente tanto para autorizar a condenação quanto para a manutenção de qualificadora negada pelo acusado, desde que seus depoimentos sejam plausíveis, coerentes, seguros e estejam em harmonia com as demais provas existentes. (TJMA, Acr 005033-2004 - (50.084/2004), 2ª Câmara Criminal, j. 03/06/2004)

PENAL - ROUBO QUALIFICADO - SUBTRAÇÃO - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - 1) Provado que os agentes, em concurso, subtraíram dinheiro da vítima, mediante grave ameaça e violência, causando-lhe lesão de natureza grave, incensurável a sentença que os dá como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, primeira parte, do CP. 2) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, demonstrando plena convicção dos autores do roubo, reveste-se de relevante valor probatório e consistente elemento seguro para formar o convencimento do juiz sentenciante. 3) Apelo improvido. (TJAP, Acr 170603 - (6321), Câmara Única, j. 16/12/2003).

No mais, ausentes contradições nas declarações quanto ao cerne dos fatos, não pode ter a sua perspectiva descreditada por qualquer via.

Em consonância com o exposto, Christian, testemunha de acusação, afirmou ter sido

acordado pelo irmão, noticiando que, da janela, avistou a entrada de algum desconhecido na residência da vítima. Sua versão foi de toda igual à do vizinho e amigo e, quando questionado, também soube reconhecer o acusado. Em igualdade, o policial militar que atendeu a ocorrência testemunhou corroborando com o asseverado.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita." (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório." (TacrímSP - RT 530/372).

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal nº 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTA VOL-01846-02 PP-00293).

Não é demais dizer que o réu foi preso em flagrante delito, fato que, segundo Rafael Magalhães (apud Tourinho Filho) "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, in Do flagrante delito, 1933, pág. 25. Nesta toada, de acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento quando se comete um crime. E continua, ensinando que "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova eloqüente do crime e da respectiva autoria." (in Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

Em adição ao todo produzido, o próprio réu confessou, ao menos parcialmente, confirmando a intenção da empreitada, eis que, quando da audiência de instrução, debates e julgamento, ele narrou que entrou na residência com o fim de tentar furtar a televisão e o notebook da vítima.

Segundo afirma, teria desparafusado o primeiro item e o segundo apenas separado, colocando-o numa sacola do lado de fora da porta, falhando neste procedimento, posto que flagrado por uma vizinha. Em sua versão, seu contato com a vítima deu-se somente mais tarde quando, já na rua, quadras à frente do prédio, ela dirigia um veículo vermelho na companhia de um homem gordo, que saiu do carro e foi agredido, sofrendo escoriações, com dentes e celular quebrados.

A despeito de sua versão se apresentar pontos confusos e ser contraditória àquela que relatou em sede de inquérito, ao menos confirma sua ação criminosa central, que era a subtração dos bens da residência.

Deste modo, convencido o juízo no que tange à autoria e à materialidade do crime. Não obstante, a tipificação levantada pelo Parquet, acerca do cometimento do crime de roubo impróprio, se amoldura obscura.

Isto porque, a despeito da confirmação dos dizeres da vítima narrando o evento criminoso e confissão do réu sobre a subtração, a suposta violência em si, resta incerta, devendo ser acolhida a tese de defesa para desclassificação do crime.

Em seu depoimento, não conseguiu precisar exatamente se o réu teria executado qualquer ato violento contra si ou se houve mera tentativa de fuga e defesa contra a perseguição.

Aliás, somente a informação que “foi para cima de mim”, como dita a vítima, por si, não implica necessariamente em violência, podendo se tratar da forma de escape da situação ou mesmo mero método para desorientação, não podendo ser presumido o intuito de dano físico. Aliás, inclusive confirma que não houve tentativa de agressão imediata, mas de passar por ele.

Pela dinâmica informada, inclusive, atrás da vítima estava a porta que seria a rota natural de fuga, o que aumenta a dúvida sobre o avanço ser realmente direcionado para macular sua integridade.

Em resumo, sua narrativa restou vaga somente quanto a este ponto. Menciona que houve confronto, mas não detalha com exatidão a violência supostamente exercida.

Em soma, nenhuma outra testemunha de tais fatos agressivos.

Há, portanto, severa dúvida acerca da ocorrência de verdadeira violência, o que afeta, então, o núcleo da tipificação proposta na acusação, eis que a incerteza deve favorecer o réu.

Logo, uma vez não preenchido o elemento violência ou grave ameaça, desconfigura-se o crime de roubo imputado pela acusação.

Em verdade, mais adequada seria a subsunção em consonância ao crime de furto, tipificado pelo códex penalista brasileiro, por meio do seguinte dispositivo:

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Todavia, diversamente do advogado pela Defesa, sopeso que, pela própria descrição fática, constata-se que o iter criminis se completou, não devendo o ato ser considerado como meramente tentado.

Pela teoria da Amotio, hoje adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento exarado sob a sistemática de julgados repetitivos, basta a inversão da posse da coisa para consumação do delito patrimonial, sendo indiferente a perseguição da vítima ou a recuperação da coisa.

Tema repetitivo 934: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Em aplicação da teoria, cita-se como exemplo:

[...] 4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de

vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. 5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante. (STJ. 5ª Turma, HC 618.290/RJ, j. 17/11/2020).

Ainda pelo Egrégio Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Simples - Art. 155, caput, do CP - RECURSO DEFENSIVO - NÃO DISCUTE O MÉRITO - Autoria e materialidade devidamente comprovados. Pugna pelo reconhecimento do crime de furto em sua forma tentada - IMPOSSIBILIDADE - Nos moldes da teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1506629-13.2020.8.26.0228; Relator(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021).

Dessa forma, ante ao todo fundamentado, satisfatoriamente comprovados os indícios da autoria, assim como a prova da materialidade, impõe-se a condenação pelo crime de furto simples consumado.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, observado o critério trifásico.

Em fundamentação à aplicação das penas, observo que os motivos, a personalidade do agente, a conduta social e as consequências do crime não são especialmente reprováveis. A culpabilidade da conduta também já foi mensurada no estabelecimento dos parâmetros abstratos de pena no tipo penal incriminador.

Em exclusão da condenação mais recente (58612-10 - págs. 85/86), que será utilizada para fins de reincidência, o réu ainda possui outras 05 condenações criminais, inclusive específicas, transitadas em julgado antes do fato (págs. 51/58), e, sabendo que o período depurador somente serve para fins de consideração de reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes, que podem ser considerados a despeito de qualquer marco temporal, razoável majoração da pena-base em 1/3, estatuinto-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase do sistema trifásico, incide a agravante da reincidência específica a ser considerada pela condenação em 2010 no referido processo 58612-10, acarretando novo aumento.

Registro que, a despeito de sua condenação antiga, o cumprimento da pena somente teria término de cumprimento em 2021, conforme págs. 85/86 e informação de pág. 80, em que em última comutação de maio de 2020, ainda faltava mais de um ano de pena a cumprir.

Também, há a atenuante da confissão parcial (artigo 65, inciso III, alínea "d", combinado o artigo 66 do Código Penal) a cotejar com referida agravante.

Neste tópico, cumpre sublinhar que apesar de o réu ter somente confessado aquilo que consta evidente no processo (diante da situação de flagrância) não afasta a incidência da atenuante, nos termos da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que deve incidir em todos os casos que auxiliam o convencimento do julgador, mesmo que de menor incidência.

E, no tópico, não se olvida a divergência com relação à possibilidade ou não de compensar a agravante em comento com a atenuante da confissão, contudo, a norma penal é expressa na quanto à preponderância da reincidência, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Conquanto, compreendo, no caso, que é possível que o aumento seja gradativamente menor em função da existência de atenuante, mesmo que esta não sirva para excluir por completo a majorante.

Nesta linha, o aumento deve ser de 1/8, totalizando a pena de 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo por que a pena será a acima fixada.

Dada a quantidade de pena impingida, reincidência específica e o teor da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial de pena será o semiaberto, adequada à gravidade do fato praticado e às múltiplas condenações do réu. E, sendo reincidente, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44, inciso II, Código Penal), certo de que já foi condenado pelo crime de furto no passado e, pela diversidade de outras condenações, ser a medida não socialmente recomendável, tenho que incabível a aplicação do §3º do Código Penal. Em igualdade, inaplicável a substituição da pena (artigo 77, inciso I, Código Penal).

Dispositivo.

Ante ao exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para condenar o réu, JEAN CARLOS MIOTTO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, às seguintes penas: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, nos valores mínimos legais. Considerando a ausência de comprovação de cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime, na forma do artigo 112, §1º, da Lei de Execuções Penais, deixo de aplicar a detração da pena (§2º do artigo 387 do Código de Processo Penal).

Outrossim, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de requerimento específico do Ministério Público e de contraditórios neste sentido. No que concerne ao bem apreendido na Delegacia de Polícia, um telefone-celular de marca Samsung, sem marca aparente, cor roxa, devidamente acondicionado em invólucro plástico com lacre (pág. 8), não havendo indícios de sua ilicitude, determino a sua devolução.

Por fim, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, além do tempo de prisão cautelar experimentado – suficiente para acautelar a ordem pública abalada pelo delito, de rigor a concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto manter a prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representaria a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele ora estabelecido.

Nesse sentido, destaca-se que, em julgados recentes, o E. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se considerou ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTES SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185181 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020).

HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES ADEQUAÇÃO. Ausente demonstração de dedicação do paciente a atividades criminosas, surge adequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTO TÍTULO CONDENATÓRIO REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A previsão do regime semiaberto para o cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva, cujo cumprimento dá-se no fechado, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a do título condenatório. (HC 180016, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020) (grifei).

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade. Violação ao princípio da individualização da pena. Inadmissibilidade. Sistema trifásico devidamente observado em favor do acusado MAICON. Preliminar rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réus confessos. Dosimetria. Pleito de redução da fração de diminuição relativa ao reconhecimento da forma tentada do delito. Possibilidade. Acusados que percorreram iter criminis intermediário. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Cabimento. Arma apreendida que estava desmuniada. Ausência de potencial lesivo. Penas redimensionadas. Abrandamento do regime prisional fixado em desfavor dos apelantes. Cabível. Quantum da pena e demais circunstâncias do delito que autorizam a fixação do regime inicial aberto aos acusados MAICON e ÍTALO, e do regime inicial semiaberto ao apelante CARLOS, em razão da reincidência por ele ostentada. Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Revogação da prisão preventiva dos apelantes. Regimes prisionais fixados incompatíveis com a prisão preventiva. Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500054-83.2021.8.26.0153; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021) (grifei). Assim sendo, REVOGO a prisão preventiva do réu, autorizando o recurso em liberdade (artigo 387, §1º, do Código Penal). Expeça-se alvará de soltura clausulado. Com o trânsito em julgado, providencie o necessário para cumprimento e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santos, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA